

Conselheiro Maxwell Borges de Moura Vieira

Tribunal Pleno – **SEÇÃO MUNICIPAL**

Sessão: **25/06/2025**

Cautelar em Procedimento de Contratação – **REFERENDO E JULGAMENTO**

M-001: TCS-006970.989.25-7; 007112.989.25-6
Interessada: Prefeitura de Franco da Rocha
Responsável: Lorena Rodrigues de Oliveira
Representantes: AJSantos Distribuidora Ltda.; Merenda Mais de São José Alimentos Ltda.
Assunto: Representação formulada em face do edital do Pregão Eletrônico nº 02/2025, instaurado pela Prefeitura de Franco da Rocha, objetivando o fornecimento de gêneros perecíveis (hortifrutigranjeiros) para atendimento às unidades escolares.
Valor estimado: R\$ 3.555.047,00 (Lote 1); R\$ 1.133.497,96 (Lote 2); R\$ 350.604,00 (Lote 3)
Advogados cadastrados no e-TCESP: Ricardo Fenício Antonino – OAB/SP 349.892

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. GARANTIA. FICHA DE PROCEDIMENTOS. NUTRICIONISTA. ATESTADOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CORREÇÕES DETERMINADAS COM RECOMENDAÇÕES.

1. A Administração deverá reavaliar a exigência da garantia da proposta, adequando a sua finalidade ou convertê-la em garantia contratual.
2. Impertinente a exigência da apresentação da Ficha de Procedimentos, já que a imposição revela uma indevida restritividade ao certame.
3. Indevida a apresentação de documentos afetos ao profissional Nutricionista nas aquisições que envolvem a comercialização de produtos “in natura”.
4. Possível a exigência de prova de aptidão para este objeto, devendo ser aclarados os quantitativos requeridos.
5. Recomenda-se à Administração que reveja a especificação dos produtos ditos como de “primeira qualidade”, nos termos propostos pela Chefia do DIPE.

Relatório

Trata-se de representações formuladas por AJSantos Distribuidora Ltda. e Merenda Mais de São José Alimentos Ltda. em face do Pregão Eletrônico

nº 02/2025, instaurado pela Prefeitura de Franco da Rocha, objetivando o fornecimento de gêneros perecíveis (hortifrutigranjeiros) para atendimento às unidades escolares, nos termos definidos no ato convocatório.

De forma breve, a primeira reclamou das seguintes exigências:

- a) garantia da proposta (item 9.5);
- b) ficha de procedimentos (item 12.9.3.2);
- c) registro profissional do nutricionista – CRN (item 12.9.3.5);
- d) certidão junto ao Conselho Regional de Nutricionistas (item 12.9.3.6);
- e) atestado de responsabilidade técnica emitido pelo CRN (item 12.9.3.7);
- f) comprovação de vínculo da Nutricionista (item 12.9.3.8);
- g) certidão negativa de débitos da nutricionista junto ao CRN (item 12.9.3.9);
- h) atestado de capacidade técnica sem clareza quanto ao quantitativo (item 12.9.3.1); e
- i) valor fixado para a comprovação do patrimônio líquido ou capital social.

Já a Representante remanescente acresceu as seguintes queixas:

- j) Aglutinação do objeto;
- k) Especificações;
- l) Ausência de justificativa técnica detalhada; e
- m) Fracionamento exigido das embalagens.

Considerando a necessidade de uma apreciação mais pormenorizada, sobretudo por sinais de indevida restritividade imposta ao certame, ou mesmo de confronto com a legislação aplicável, recebi a matéria nesta via processual (evento 13 do TC-006970.989.25-7).

Na sequência, a Origem trouxe aos autos a documentação e suas justificativas (evento 25, TC-006970.989.25-7).

A Assessoria Jurídica e Chefia do DIPE opinaram pela procedência parcial das impugnações – posição acompanhada pelo Procurador de Contas (eventos 39 e 43 – TC-006970.989.25-7).

É, na essência, o relatório.

fnp

Voto

TC-006970.989.25-7

TC-007112.989.25-6

Em preliminar, peço referendo à decisão monocrática que recebeu a matéria nesta via processual.

No mérito, inicio pela crítica dirigida à garantia da proposta.

Sobre este tema, ainda que legítima a imposição, inclusive quanto ao patamar requerido (1% do valor estimado por lote), a justificativa contida no subitem 9.5.1 do edital apresenta argumentos que amparam exigência diversa (garantia contratual), de propósito distinto, conforme constatado pela Assessoria especializada.

Vide o teor daquela cláusula:

“9.5.1 - A Justificativa da exigência de garantia da proposta tem como objetivo de minimizar o risco de interrupção ou falha no fornecimento de hortifruti, sendo que se trata de um fornecimento contínuo de produtos perecíveis com entrega ponto a ponto, que visa garantir uma alimentação saudável, balanceada e nutritiva para os alunos. Tal exigência é necessária para resguardar a execução eficiente e dentro dos parâmetros acordados, garantindo o cumprimento das obrigações contratuais e continuidade do fornecimento que é essencial para os alunos.”

Amparado nestes propósitos, a Administração deverá reavaliar a exigência de forma a, caso insista na demanda, ajustar as justificativas para a sua real finalidade ou, alternativamente, convertê-la em garantia contratual, a ser exigida no momento da assinatura do contrato.

Quanto à ficha de procedimentos, desnecessárias maiores delongas acerca da impertinência deste documento, já que revela uma indevida restritividade do certame – posição pacífica em nosso entendimento jurisprudencial - mesmo porque, para estes fins, basta a exigência de licença de funcionamento, já requerida no edital.

Nessa linha, cito excerto do r. voto contido nos autos do TC-20779.989.24-3 e outros, acolhido pelo Tribunal Pleno na sessão de 27/11/2024:

“Procede, do mesmo modo, a reclamação contra o item 5.1.2 do Anexo I, no ponto onde exige ficha de procedimentos emitida pela Vigilância Sanitária ou check list da legislação pertinente, emitido pela Vigilância Sanitária, junto à licença de funcionamento da Autoridade Sanitária. Veja que questão idêntica em objeto similar da própria Prefeitura Municipal de Guarujá já foi julgada procedente nos processos TC-5607.989.23-3, TC-5698.989.23-3 e TC-5728.989.23-7[.]”

Igualmente procedente as críticas pontuadas nas alíneas “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do relatório – todas relativas ao profissional Nutricionista. Esta intelecção decorre do fato que, nas aquisições envolvendo apenas a comercialização do produto *in natura*, exigências da espécie se mostram desnecessárias e, por via reflexa, inibem, de forma injustificada, a amplitude do universo de competidores.

Confira-se, a respeito, julgado contido nos autos do TC-6814.989.22-4 (Tribunal Pleno de 23/3/2022):

“A jurisprudência desta Corte condena a imposição de a licitante comprovar responsável técnico que desempenhe atividades não correlatas ao objeto licitado. No caso, a aquisição de hortifrutigranjeiros não é compatível com a necessidade de comprovação de responsável técnico na área de nutrição ou agronomia, por exemplo, tendo em vista que se trata apenas da comercialização do produto *in natura*.”

Tema de maior relevo refere-se à possibilidade da exigência de prova de aptidão para objetos que envolvam simples fornecimento de bens.

Relembro que, recentemente (sessão de 19/3/2025), este Tribunal se debruçou sobre o tema e, após intensos debates, acolheu a tese da viabilidade da obrigação (TC-24546.989.24-5), cujo objeto também se referia à aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da merenda escolar. (Relatoria do E. Conselheiro Renato Martins Costa).

Conforme constou nas notas taquigráficas, foram considerados em favor desta tese, precipuamente, a capacidade da entrega e o manuseio adequado, como forma de não comprometer a qualidade do produto.

Dessa forma, considerando a similaridade dos objetos e as características da licitação que ora se aprecia (trata-se do fornecimento expressivo e contínuo de mais de quatrocentas toneladas em alimentos para atendimento a cinquenta e três unidades escolares do município e mais de dezesseis mil alunos matriculados, com entrega ponto a ponto), adoto o mesmo posicionamento firmado, na direção da possibilidade da exigência de prova de aptidão para o caso em disputa.

Ainda nesse tópico, atento ao reclamo da Representante quanto à falta de clareza no tocante aos quantitativos, pertinente a observação da Chefia do DIPE, já que a requisição de experiência prévia nestas situações deveria se concentrar na capacidade logística e na habilidade para transporte de perecíveis, e não de produtos específicos – raciocínio que se depreende das notas taquigráficas citadas linhas atrás.

Sendo assim, com base nas suas ponderações endossadas pelo Procurador de Contas (eventos 39 e 42 TC-6970.989.25-7), prudente que a Administração aprimore a redação editalícia para atendimento ao disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 14.133/21, limitando-se a exigir prova de fornecimento de, no máximo, 50% dos quantitativos referentes aos produtos cujos valores superem os 4,0% do total estimado para cada lote disputado.

Prosseguindo nesta apreciação, ao contrário do alegado, não há excessos no valor fixado para a comprovação do patrimônio líquido ou capital social (correspondente a 10% do valor estimado para cada lote), diante da sua franca sintonia com o art. 69, § 4º, da Lei nº 14.133/21.

Mesmo desfecho dirijo à composição do objeto, já que a segregação em três lotes distintos (lote 1 para “frutas”, lote 2 para “legumes e folhosos” e lote 3 para “ovos”) denota, a princípio, a observância às características e similaridades dos itens componente de cada grupo.

Quanto às queixas dirigidas às especificações e fracionamento das embalagens, acolho o parecer da Assessoria Específica pela improcedência, seja pelo fato de a Peticionária não ter demonstrado, de forma contundente, o excesso nos descritivos particularmente questionados, seja ainda diante dos argumentos defensórios, ao alegar que a demanda por embalagem de 1 kg para determinados itens pretende evitar desperdícios, adequando a quantidade fornecida ao consumo real das unidades escolares.

Além disso, forçoso reconhecer, ao menos em certa medida, a incidência do Poder Discricionário pelo qual se reveste a Administração e que permite, dentro dos limites legais, a tomada de suas decisões lastreadas pela conveniência e oportunidade em busca de um dado interesse público.

A propósito, como retratado nos autos do TC-14562.989.21-0 (Sessão Plenária de 18/8/2021 – vide notas taquigráficas), *matéria de ordem discricionária da Administração nem caberia análise em exame prévio de edital, por não ser ilegal, não ser inconstitucional e não afetar a formulação das propostas.*

De qualquer forma, sensibilizado pela primazia do parecer emitido com a propriedade que lhe é peculiar pela Chefia do DIPE, na qual traz comparativos de Estudos do CADTERC e do CEAGESP especialmente sobre o que seria produtos de “primeira qualidade”, recomendo que a Administração reveja esta especificação nos termos pontuados (vide evento 39-2 do TC-6970.989.25-7), mesmo porque não lhe fora oferecido o contraditório para este quesito.

Por fim, não merece guarida a insurgência concernente à “falta de justificativa técnica”, por me parecer suficientes as menções do edital relativas à observância das diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), às suas resoluções e ao Estudo Técnico Preliminar – documento disponível no processo administrativo, segundo a Municipalidade -, especialmente ao se considerar a natureza da aquisição (bens comuns), consoante defendido pela Órgão Instrutivo/área técnica.

Diante do exposto, voto pela procedência parcial dos questionamentos reproduzidos, devendo a Prefeitura de Franco da Rocha:

- a) rever a exigência da garantia da proposta;
- b) retirar a obrigatoriedade da apresentação da Ficha de Procedimentos;
- c) extrair as exigências afetas ao profissional Nutricionista; e
- d) aperfeiçoar a redação da prova de aptidão especialmente quanto aos quantitativos requeridos.

Recomendo, outrossim, que a Administração reveja a especificação dos produtos ditos como de “primeira qualidade”, nos termos propostos pela Chefia do DIPE.

Ao republicar o edital com as devidas alterações, a Administração deverá observar a reabertura do prazo legal, em obediência ao que preceitua o artigo 55, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

Acolhido este entendimento pelo Plenário, intime-se a Representada, na forma regimental.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

É como voto.